

0015762-34.2018.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Seqüestro e cárcere privado

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... 1a. Vara de Taboão da Serra por delito de roubo). Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, referidas condenações, conquanto não configurem reincidência, podem ser valoradas negativamente na primeira fase, como maus antecedentes. Neste sentido:(...) Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0015762-34.2018.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015762-34.2018.8.26.0161

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere privado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 287/2010 - 1º Distrito Policial de Diadema, 3543/2010 - 1º Distrito Policial de Diadema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fagner Clayton de Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

FAGNER CLAYTON DE LIMA, qualificado às fls. 125, FABIANO SCAGLIA, LÚCIO TELLES RIBEIRO e ARNALDO DONIZETE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO, qualificados nos autos, foram denunciados perante este Juízo como incurso no art. 148, §2º e artigo 163, parágrafo único, III, na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, porque no dia 11 de junho de 2010, atuando previamente ajustados entre si, com unidade de desígnios e divisão de tarefas para o fim comum, privaram a vítima Paulo Henrique Pereira da Silva de sua liberdade, mediante cárcere privado, resultando-lhe, em razão de maus tratos e da natureza da detenção, grave sofrimento físico e moral. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, os réus previamente ajustados entre si, com unidade de desígnios, destruíram e deterioraram coisa alheia pertencente ao patrimônio do Estado de São Paulo consistente no corte da tela metálica da cobertura.

A denúncia foi recebida em 15/09/2016 (fl. 270). O acusado Fagner foi declarado revel e os autos foram suspensos e desmembrados em relação à ele, nos termos do art. 366 do CPP (fl. 468), sendo citado nestes autos à fl. 638, com constituição de

Advogado, apresentando sua defesa prévia às fls. 618/626.

Instalada a audiência, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e interrogados os réus ao final.

Em debates orais o Ministério Público requereu a condenação dos acusado, uma vez que os fatos descritos na inicial restaram cabalmente comprovados, fixando-se as penas base bem acima dos mínimos legais ante os maus antecedentes e circunstâncias e consequências dos crimes, com cumprimento em regime semiaberto, sem possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos.

Já a Defesa pugnou pela absolvição dos acusado ante a fragilidade probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas em seu mínimo legal, em regime mais brando e possibilidade de apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/13, laudo pericial atestando o dano no local (fls. 26/27) e de lesão corporal à vítima (fl. 202), bem como a prova oral amealhada. Ressalto que: [...] no cárcere privado (que constitui uma espécie do gênero seqüestro), a privação de liberdade ocorre em recinto fechado, enclausurado, confinado (p. ex. manter a vítima em quarto fechado. Note-se que a privação de liberdade não precisa ser total; basta que a vítima não possa desvencilhar-se do seqüestrador sem que corra perigo pessoal para que se configure o crime em tela. (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2004. V.2)

A autoria é inconteste.

O ofendido Paulo Henrique Pereira da Silva, ouvido em sede policial (fls. 62, 96 e 110), declarou que foi rendido pelos indiciados que ameaçam sua vida, sendo levado a casa de máquinas, onde teve o punho e as pernas amarradas. Foi ameaçado de ser jogado de cima do prédio prisional, caso os indiciados tivessem a fuga frustrada e a polícia invadissem o local. Os acusados afirmavam que seria utilizado de escudo humano. Os indiciados desistiram da idéia e usando uma "Tereza" desceram pela fachada externa do presídio até a linha de tiro, ocasião que foram interceptados e detidos pelos agentes de segurança. Declarou que sofreu lesões nos punhos e nas pernas em virtude de estar amarrado.

Perante ao Juiz Imparcial, a vítima disse que faz muito tempo e por isso tem pouco lembrança. Estava no último andar do CDP de Diadema fazendo ronda. Observados os dois pátios, pois ao banheiro, e ao sair, percebeu movimentação estranha, porque tinha muita água como um vazamento e viu vultos, mas estranhou porque estava sozinho. Eram os presos, que lhe pegaram e perguntavam se estava sozinho e disse que sim. Não tinha como sair pelo portão principal porque trancado com cadeado. Então queriam fugir por outro jeito e que iam usa-lo como escudo. Tiraram toda sua roupa e lhe amarraram mãos e pernas numa cadeira e o deixaram na casa de máquinas dos elevadores. Ameaçaram de lhe jogar lá de cima se algo desse errado. Foram momentos difíceis que marcaram por toda sua vida. Passou-se muito tempo ali como refém. Até que foi chamado pelo rádio HT, que já estava na mão deles. Seus amigos policiais perceberam, e depois de umas três ou quatro horas, eles deixaram a carceragem e foram para o prédio da administração. Até que veio apoio e foi desamarrado, ficou psicologicamente abalado e fisicamente esgotado. Foi para o hospital onde soube que seu dedo ia gangrenar se ficasse um pouco mais de tempo, tanto que ficou sem sentir sensibilidade nos dedos por conta dessa agressão por um bom tempo. Eles cerraram a tela da parte de cima do pátio de sol e por ali saíram e tiveram acesso de onde estava. Eles estavam com duas cordas, uma tipo Tereza de onde desceram até a laje e ficaram lá sem saída, porque tinha um tipo de ouriço e não conseguiram sair. No dia era mais de quatro presos. Não deixavam olhar para eles. Por conta do tempo decorrido, não tem condições de fazer o reconhecimento pelas mudanças físicas nesse período, mas tem certeza que todos os que foram presos no dia atuaram contra si. Às reperguntas, disse que não tem como identificar, precisar quem fez o quê, porque um incentivava o outro a agir. E é difícil identificar o preso, é mais fácil ser reconhecido por eles. Já faz dezesseis anos passados, e as pessoas mudam muito, engordam, emagrecem, mudam o cabelo. Enfim, os

presos responderam sindicância, uns quinze, que teriam também tentado fugir pelo mesmo local danificado, mas teve contato com uns quatro só, os que desceram na laje e ali ficaram encurralados. Não estava em condições de depois de ser resgatado, fazer o reconhecimento ou ter contato com esses quatro presos na laje, depois de descerem por uma corda tipo Tereza, ao que soube e depois viu a corda. Foi socorrido ao hospital. Existia câmera, mas não lembra se tinha uma câmera bem no local dos fatos. Os indivíduos mandavam não olhar para eles. Ficou de cabeça baixa. Um deles colocou sua blusa, seu óculos, tentando se fazer passar por si. Quando saiu do banheiro, eram mais de quatro ou cinco, e já foi amarrado. Acha que todos participaram da cerragem da grade para assim saírem e terem acesso ao banheiro onde estava.

Os policiais militares, ouvidos extrajudicialmente (fls. 42 e 44), declararam que estavam de patrulhamento de rotina, quando foram acionados pelo COPOM para comparecerem ao CDP de Diadema, onde estava ocorrendo uma rebelião. Quando chegaram no local, a situação já estava mais apaziguada, e em contato com o agente penitenciário Paulo Henrique, este informou que estava exercendo as suas funções de rotina no quarto andar, quando foi rendido por alguns dos detentos, os quais levaram até a sala de máquinas do elevador desativado, tendo seus punhos e pernas amarradas, sendo ainda constantemente ameaçado de morte, caso a fuga fosse frustrada, posteriormente os detentos desistiram da fuga e desceram pela parte externa do prédio usando uma "Tereza", sendo interceptados por agentes penitenciários.

Em juízo, o policial militar Eduardo Santana respondeu que não se recorda bem da ocorrência. Fez diversas incurssões de tentativa de fuga de preso no CDP de Diadema.

Neste sentido foi o depoimento do miliciano Michael Mendes recordou-se que o Copom chamou para o CDP por indivíduos em fuga. A vítima disse que foi abordada por quatro presos onde foi amarrado na casa de máquinas e fizeram tortura psicológica e que ele seria usado como escudo humano. Eles colocaram uma corda Teresa e foram interceptados no pátio. Os quatro foram detidos, estavam muito agressivos. A vítima foi encaminhada ao médico. Os quatro réus presos foram os que ficaram encurralados pela laje após descerem por uma corda Tereza até a laje. Não entrou no CDP para ver o dano no local, na grade. Recorda-se pouco do réu em virtude do tempo decorrido. Não tem mais acesso ao CDP após o ocorrido no Carandirú, então não sabe informar nada de seu interior.

O indiciado Fagner, em sede policial, ficou-se silente (fl. 125)

Sob o crivo do contraditório, o réu recordou-se da fuga da qual participou com outros presos. Não se recorda de quem cortou a grade. Foi preso com outros presos que também tentaram a fuga. Não conseguiu voltar. Foi colocado numa viatura e foi para CDP de Pinheiros e de lá para Presidente Venceslau. A tela já estava danificada. Foi muitos presos que passaram. Alguns voltaram, mas não conseguiu. Não chegou perto do funcionário, não encostou nele. Rendeu-se na laje. Estava no pátio de sol. Começou a subir presos e então um deu o ombro para o outro subir. Viu o funcionário preso e desceu com os outros por uma corda de lençol. Consigo foram mais dois que ficaram na laje para onde desceram por uma corda tipo Tereza. Ficou um tempo detido. Morava com a sogra e depois comprou uma casa e ninguém lhe procurou na casa de sua sogra, por isso o processo ficou suspenso até ter conhecimento. Já foi processado por assalto. Foi o último a descer e após veio um tiro de advertência e mais ninguém desceu. Dai virou um motim.

Diante das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais tem-se prova cabal a embasar a condenação pelos dois crimes. Assim, afastou-se a tese defensiva de fragilidade da prova quanto a autoria delitiva, pois apenas os quatro réus foram detidos após terem passado pela grade que foi cortada e terem tido acesso à laje por onde desceram por uma corda (vulgo "tereza"). E só não conseguiram lograr êxito na fuga da prisão por conta das cercas tipo concertinas. Inclusive, conforme dito pela vítima e não provado o contrário pela Defesa, não tinha como os demais presos terem acesso ao local do dano se não passassem pela tela metálica, e apenas os réus o fizeram, de modo que foram eles que cortaram a tela, embora a vítima não tenha

presenciado isso, pois estava amarrada a uma cadeira, sem possibilidade de locomoção. E machucada, pois teve mãos e pernas amarradas, quase perdendo um dedo que gangrenou. E debilitada psicologicamente diante das ameaças de ser usada como escudo humano e de ser jogado lá de cima. Assim, foi causado a ela grave e desnecessário sofrimento físico e psíquico, constatado até pericialmente, pelo laudo de fls. 202, documento de fls. 16/18, corroborado pelos relatos de todas as testemunhas, como visto.

No mais, é certo que na data dos fatos, diga-se, mais de doze anos passados, a vítima havia reconhecido os acusados, além de não haver possibilidade de terem sido outros detentos os autores tanto do dano ao patrimônio quanto do cárcere privado, pois apenas os réus tiveram acesso ao local onde o ofendido estava trabalhando. Assim, não se tem como afirmar não terem sido eles os autores dos dois crimes em questão, como pretende a Defesa e não provou. Ainda, houve prévia anuência entre o réu e os demais presos, com divisão de tarefas, para fugirem da prisão, necessitando cortar a grade, dali galgar o local onde a vítima estava, faze-la refém, e tentarem fuga através da corda tipo Tereza que os levou até uma laje de onde não tinham saída, ficando encurralados e ali detidos.

Não se alegue que foram mais de quinze agentes que responderam à Sindicância, e que por isso não teria sido o réu quem efetivamente danificou patrimônio público, ou seja, o corte da grade, que segundo ele já estaria danificada, não fazendo prova disso como lhe competia o ônus dessa prova nos termos do art. 156 do CPP, o que também se aplica a alegação de que por haverem outras pessoas envolvidas, não teria sido o réu quem restringiu a liberdade da vítima, ou seja, que não foi ele quem a amarrou, não fazendo prova de quem o teria sido então, como lhe competia esse ônus do que afirma. Ora, o contexto probatório indicou que com certeza quatro indivíduos, dentre eles o réu, foram os que tiveram acesso ao pavimento onde a vítima estava, e isso só foi possível após a danificação da grade, patrimônio público. Daí tiveram acesso à vítima, que foi então rendida e torturada física e psicologicamente. Como não conseguiram voltar, tiveram que descer por uma corda tipo Tereza até uma laje, onde ficaram encurralados e ali foram capturados. Isso indica que o réu foi um dos primeiros a agir com seus comparsas e, por consequência, os que danificaram a grade e amarraram a vítima, senão, ele teria conseguido voltar e não ser preso.

Embora a vítima, passados mais de doze anos, traumatizada com o ocorrido, e nessa condição não tenha tido possibilidade de reconhecer o acusado nem de detalhar qual a conduta de cada um dos quatro agentes, isso não induz à automática absolvição, como pretende a Defesa, quer pelas circunstâncias já ditas, quer porque a vítima não podia ficar olhando seus algozes, observando suas tatuagens, cicatrizes, como pretende a Defesa, e por isso, por impossibilidade de olhar o que se passava e olhar a fisionomia e demais características dos presos, foi que não pode identifica-los melhor, menos ainda a conduta específica de cada um. Mas o ofendido afirmou que os quatro detentos que foram presos são com certeza os que lhe renderam depois de cerrarem a grade por onde tiveram acesso.

E nem se alegue que o réu não foi visto pela vítima nem por câmeras de segurança ou outro agente cortando a grade do CDP e por isso deva ser absolvido. Ora, como visto, ele foi um dos primeiros a ter acesso ao local, que sem o dano na grade, não conseguiria chegar no local onde a vítima estava. Tanto que se ele tivesse sido visto, já teria sido detido. E sem esse dano, ele não teria tido acesso aos demais compartimentos do CDP, de modo que não se tem como afastar sua responsabilidade nem autoria também com relação ao delito de dano.

Ora, como já visto, e segundo a vítima, foram os réus, dentre eles o ora sentenciado, quem lhe amarraram à cadeira e lhe ameaçaram o tempo todo de morte, quer que o fariam de escudo humano, quer que o jogariam do quarto andar do prédio, tendo ficado com sequela psíquica por anos, sob tratamento inclusive à base de remédio que o deixaram afastado do serviço. E embora não se recorde mais das fisionomias de seus algozes, até pelo tempo decorrido, doze anos, e principalmente pelo abalo e trauma que sofreu, por tudo o que passou, a dificultar falar e reviver situação tão delicada e traumatizante, isso não significa que o réu deva ser absolvido.

Vê-se, pois, que os depoimentos e as conclusões dos laudos periciais são coerentes e convergentes, não tendo sido descaracterizadas pela defesa, devendo ser levados em conta e são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando suficientemente demonstrada a autoria do réu em relação aos crimes imputados, não tendo o menor cabimento a pretensão defensiva de alcançar a absolvição a qualquer título que seja.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências, especialmente o abalo à saúde mental da vítima, que teve até que se afastar do trabalho, e o fato de quase ter perdido um dedo, o que será levado em consideração a aumentar a pena base para uma mais justa individualização quanto à pena do crime de cárcere privado que deixou sequelas traumatizantes na vítima. Verifico ainda, que o acusado ostenta duas condenações com trânsito em julgado, com datas posteriores ao delito apurado nestes autos, mas que se referem a fatos anteriores (processo n.º 0005064-47.2010.8.26.0161, fls. 669/670 e 672 -processo que tramitou na 1a. Vara de Taboão da Serra por delito de roubo). Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, referidas condenações, conquanto não configurem reincidência, podem ser valoradas negativamente na primeira fase, como maus antecedentes. Neste sentido:(...) Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente os antecedentes do réu. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela e contemporânea à condenação, seja utilizada como circunstância judicial negativa ((HC 459.108/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019 - grifei). Some-se a isso o fato do réu ter ficado revel, com o feito suspenso com relação a si, por mais de doze anos a demonstrar seu descaso para com a justiça e maior perda de tempo e gasto judicial, donde fixo, em primeira fase, as penas-base acima do mínimo legal, ou seja, ou seja, em 03 anos de reclusão para o crime de cárcere privado, e em 07 meses de detenção e 11 dias-multa para o crime de dano.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem consideradas, mantendo-se as penas inalteradas nessa fase.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento nem de diminuição de pena, que serão somadas nos moldes do art. 69 do CP, totalizando 03 anos de reclusão mais 07 meses de detenção mais 11 dias-multa.

A despeito da quantidade de pena aplicada e considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade para o delito de cárcere privado com fundamento no artigo 33, § 3.º, e § 2.º, alínea "b" (a contrariu sensu) do Código Penal.

Nesse sentido: (...) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. ALTERAÇÃO.

Materialidade e autoria incontestes. A imposição de início de cumprimento da pena prisional em regime fechado mostra-se razoável diante do delito cometido.

Circunstâncias do delito que demonstram perigosidade. Crimes contra a patrimônio cometidos com violência e grave ameaça que propagam desassossego na sociedade.

Rigor no tratamento penitenciário inicial do réu que se coaduna com o princípio da ressocialização dos condenados. Regime de cumprimento que não deve ser fixado unicamente com base no "quantum" da pena. Exegese do art. 33, § 2.º, do Código

Penal. Sentença condenatória reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação n. 0000057-46.2012.8.26.0083, Relator(a): Amado de Faria, 3.ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 25/06/2013, Data de registro: 28/06/2013).

E ainda: (...) Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo ilegalidade a ser sanada. Precedentes (STJ, HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18/10/2016).

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena para o delito de dano, com fundamento no artigo 33, § 1.º. Alínea "c", § 2.º, alínea "c" e § 3.º, do Código Penal.

Sem substituição de pena nos moldes do art. 44 do CP ao réu, por entender não ser cabível, por insuficiente e ineficaz à reprovação da conduta e ressocialização do réu, pois praticado com violência à pessoa e grave ameaça, além de não ser socialmente recomendável tal benesse, quanto mais após anos em que o réu ficou foragido.

O sentenciado poderá apelar em liberdade por estar solto no decorrer da instrução processual, tendo comparecido aos atos em que intimado.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação de dano por ausente pedido.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em Juízo contra o réu FAGNER CLAYTON DE LIMA, qualificado às fls. 125, como incurso no artigo 148, §2º e artigo 163, parágrafo único, III, na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, e o faço para CONDENA-LO à pena de 03 anos de reclusão em regime inicial semi-aberto, mais 07 meses de detenção em regime aberto, mais ao pagamento de 11 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à data do fato, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, em 100 Ufesps, ante a constituição de Advogado particular, sem pedido de concessão de justiça gratuita, nem juntada de declaração de hipossuficiência, nem prova dessa.

Permito o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Comunique-se a vítima.

Oficie-se ao IIRGD e TRE .

P.I.C.

Diadema, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA